

1529508-63.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... ostenta condenação anterior por crimes de roubo majorado e corrupção de menor (processo nº 0001153-25.2017.8.26.0050, da 27ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 03/09/2018). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), culminando com a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1529508-63.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529508-63.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2262329/2020 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 9683863 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 3150/20/328 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 3350/20/328 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 2262329 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE LIMA DE SOUSA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

DIEGO HENRIQUE LIMA DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, cc. o artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 69, caput, cc. o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/4), na noite de 1º de outubro de 2020, por volta das 21h30, na Avenida Esperantina, nº 733, Artur Alvim, nesta cidade e Comarca, durante o estado de calamidade pública ocasionado pelo COVID-19, obteve para si vantagem ilícita no valor econômico de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em dinheiro, em prejuízo da vítima Oswaldo Pereira da Silva Filho, mediante artifício e ardil, induzindo-a em erro, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 13/16.

Ainda segundo a denúncia, alguns dias mais tarde, em 28 de outubro de 2020, por

volta das 18h30, na Rua Borges Lagoa, nº 1.450, Moema, nesta cidade e Comarca, durante o estado de calamidade pública ocasionado pelo COVID-19, DIEGO subtraiu, em proveito próprio, mediante fraude, a quantia de R\$ 4.998,98 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) da conta corrente da vítima Cecília Yuri Takahashi, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 48/50.

Narra a denúncia que, segundo apurado, no dia 1º de outubro de 2020, DIEGO, por meio de telefone clonado de Jó Meira, enviou mensagem para a vítima Oswaldo, via WhatsApp, solicitando dinheiro emprestado. Por sua vez, a vítima, acreditando que conversava com seu amigo Jó Meira, iludida pela fraude empregada, disse ao denunciado que emprestaria a quantia, mas que, no momento, não conseguia realizar a transação bancária. Sendo assim, Oswaldo pediu que o “amigo” fosse buscar o dinheiro pessoalmente. DIEGO, então, respondeu à mensagem dizendo que enviaria um motorista da Uber para receber a quantia. Assim, cerca de quinze minutos depois, um motorista do aplicativo foi à casa da vítima, a qual lhe entregou uma pequena embalagem contendo R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro. Na sequência, o motorista dirigiu-se ao endereço de DIEGO, momento em que lhe entregou pessoalmente a embalagem. Contudo, após algumas horas, ao acessar o “Facebook”, Oswaldo viu um alerta de seu amigo Jó Meira, informando que seu telefone havia sido clonado. Na sequência, a vítima conversou com Jó e percebeu que havia caído num golpe, pois, de fato, não havia sido o amigo quem lhe enviara aquela mensagem, tampouco quem havia recebido seu dinheiro.

Segundo a exordial, o motorista da “Uber”, René Elson Pereira, foi localizado e prestou esclarecimentos. Na Delegacia, identificou o denunciado, conforme Autos de Reconhecimentos Fotográfico (fl. 18) e Pessoal (fl. 26).

É ainda da inicial que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na casa do denunciado (autos nº 1529510-33.2020.8.26.0050), a polícia apreendeu um cartão de crédito e doze comprovantes bancários (fls. 31/36), dentre os quais, um comprovante de uma transferência no valor de R\$ 4.998,98 (fl. 33) realizada da conta de Cecília Yuri Takahashi para a conta de DIEGO.

De acordo com a inicial acusatória, após a localização de tal comprovante, verificou-se que, em 28 de outubro de 2020, depois de o celular de Cecília ter sido furtado (B.O. nº 1821/2020 - fls. 48/50), DIEGO logrou obter acesso à conta bancária da vítima, mediante fraude, da qual subtraiu o valor mencionado, transferindo-o para sua própria conta bancária.

Em interrogatório policial, DIEGO permaneceu em silêncio (fl. 39). Assim, a exordial conclui que, no espaço de um mês, em concurso material, o denunciado praticou o estelionato e o furto contra vítimas diferentes, consumando ambos os delitos.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 19 de novembro de 2020 (fls. 63/64).

Aos 3 de fevereiro de 2021, adveio informação de que o acusado fora preso em flagrante em outros autos (fls. 82/93).

O réu foi citado (fls. 101 e 103) e o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 107).

Por despacho datado de 5 de março de 2021, foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 108).

Em audiência de instrução realizada aos 7 de dezembro de 2022, o acusado constituiu Advogado apud acta.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima Oswaldo Pereira da Silva Filho e uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação do Réu por crime de estelionato cometido em face da vítima Oswaldo Pereira da Silva Filho. Sustentou, em suma, que no dia 1º de outubro de 2020, a vítima Oswaldo acabou ludibriado para entregar em mãos de um portador a quantia de R\$ 1.500,00. A segunda imputação diz respeito a fatos que aconteceram no dia 28 de outubro de 2020 ocasião em que a vítima Cecília teve uma quantia subtraída de sua conta. Por primeiro excluiu a imputação por crime de furto qualificado, pois a vítima não pode ser ouvida em juízo. A vítima se encontra fora do país. Remanesce o delito de estelionato. A vítima (do estelionato) confirmou a dinâmica da fraude. O réu fazendo-se passar por uma pessoa amiga da vítima acabou angariando a sua confiança. Foi utilizado um motorista de um Uber e a vítima acabou fotografando a placa do veículo. Ouvido o motorista confirmou que foi buscar a encomenda na residência da vítima para entregar no endereço do acusado. Ainda houve na sequência da investigação dois reconhecimentos, um primeiro por fotografia e ainda um segundo momento com reconhecimento pessoal a fl. 26. Requereu seja considerada a agravante da reincidência e de ter sido o crime cometido por ocasião da pandemia. Requereu a absolvição do Réu com relação à imputação de cometimento do crime de furto qualificado.

Por sua vez, o insigne Defensor constituído requereu, em suma, seja o réu absolvido com relação à imputação do crime de furto mediante fraude cometido em face da vítima Cecília, que não foi ouvida em juízo. Com relação ao crime de estelionato sustentou que não há nada nos autos que demonstre ter o réu induzido a vítima em erro. O réu não obteve a vantagem ilícita. Subsidiariamente sustentou que se trata de crime de receptação. Requereu a Defesa do acusado a absolvição nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação. Sustentou, por fim, que o réu confessou o fato.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade dos delitos narrados na denúncia.

Houve realmente a prática dos crimes de estelionato e de furto qualificado, cuja materialidade restou comprovada pelo Relatório de Investigação (fls. 9/12), pelo Boletim de Ocorrência nº 3150/2020 do 64º DP (fls. 13/14), pelo Boletim de Ocorrência nº 3350/2020 do 64º DP (fls. 15/16), pelo Termo de Declarações da vítima Oswaldo (fl. 17), pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico (fl. 18), pelo Termo de Declarações da testemunha René (fls. 19/21), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 26), pelo relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do acusado (fls. 27/30), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 31), pelos documentos de fls. 32/36, pelo Termo de Declarações e Representação da vítima Cecília (fls. 41/42), pelos documentos de fls. 43/47, pelo Boletim de Ocorrência nº 1821/2020 do 36º DP (fls. 48/50) e pelo Relatório Final de inquérito policial (fl. 51), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com relação ao crime de estelionato cometido contra a vítima Oswaldo Pereira da Silva Filho a autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a vítima Oswaldo Pereira da Silva Filho, narrou, em suma, que tem um amigo e troca informações por WhatsApp. Viajaram juntos e em dado dia, em outubro, recebeu uma solicitação desse amigo, descrevia que estava constrangido e que precisava de uma ajuda. Entrou em contato com o amigo que disse que precisaria de dinheiro, tinha esquecido de pagar um funcionário. O declarante pediu para o filho depositar, mas o banco não fez a transação em razão do valor. Passaram alguns minutos ligou para o amigo para informá-lo. Demorou um pouquinho a pessoa disse que um uber iria até o declarante buscar o dinheiro. Uma pessoa foi até o declarante para pegar o dinheiro. O declarante tirou uma foto da placa do carro. Imaginava que conversava com o amigo pelo telefone. Entregou R\$ 1500,00 para o motorista do uber. Ficou feliz em ter ajudado um amigo. Depois viu que o amigo informava ter tido o celular clonado. O declarante olhou no celular e viu que tinha a foto da placa do uber. Passou a placa para o amigo "Jó" que à época era policial. O declarante não recuperou o dinheiro.

Também foi ouvida em juízo a testemunha René Elson Pereira, que relatou, em suma, que trabalhava pelo aplicativo "99" à época. Foi uma chamada que pegou de Artur Alvim para Ferraz, tem uma modalidade no aplicativo que é para encomenda. Deixou a encomenda em Ferraz. Retirou a caixa em local próximo de onde residia e levou em um prédio em Ferraz. Fez a entrega, foi feito o pagamento da corrida. Foi chamado na polícia e a polícia queria saber se tinha feito a corrida pelo aplicativo e quem solicitou. Mostrou a chamada da corrida. Na polícia mostraram fotografias, mas não conseguiu reconhecer. Lido o auto de reconhecimento fotográfico de fl. 18 pelo Dr Promotor de Justiça, a testemunha diz que não se recorda. Lido o auto de reconhecimento de pessoa a fl. 26 a testemunha diz que tinha um rapaz em um "quarto" e realmente naquele ato reconheceu como sendo o rapaz que recebeu a encomenda. No reconhecimento pessoal só existia uma pessoa dentro do "quarto". Hoje olhando para o réu devido ao tempo não tem condições de reconhecer.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, narrando que está preso desde 1º de fevereiro de 2021, cumprindo pena por tentativa de assalto. Está com 33 anos de idade. Estudou ensino médio completo. Estava trabalhando na barbearia que tinha com o vizinho. Não conhece a vítima Sr Oswaldo. A única coisa que fez foi emprestar a conta para um rapaz chamado Felipe de Mauá. Não chegou nem a ver esse Uber. Reside na Rua Roberto Cavazana, 13. Quem provavelmente recebeu a encomenda foi Felipe, que estava na frente do prédio do interrogando. Não conhece a testemunha Rene. Não conhecia o Delegado. Não sabe porque foi feito o reconhecimento. Felipe pediu a conta e o endereço do interrogando.

No entanto, com relação ao crime de estelionato cometido em face da vítima Oswaldo Pereira da Silva Filho, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse sua versão. Consoante dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, 18ª ed., Editora Atlas, 2007, pág. 258):

"Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal."

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima Oswaldo e pela testemunha, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, sendo pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou qualquer razão concreta para

afastar a credibilidade das declarações da vítima e do depoimento da testemunha. Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar suas palavras, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado.

Do crime de estelionato – artigo 171, caput, do Código Penal.

Verifica-se que na data de 04 de novembro de 2020, a testemunha René Elson Pereira esteve na delegacia de Polícia, ocasião em que reconheceu o acusado como sendo a pessoa para quem entregou a encomenda recebida na corrida do aplicativo "99", conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado a fl. 26.

Ouvida em juízo, a testemunha René confirmou ter feito o reconhecimento na fase policial, extraíndo-se de suas declarações que tinha um rapaz em um "quarto" e realmente naquele ato reconheceu como sendo o rapaz que recebeu a encomenda.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formando um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Oswaldo, que foi induzida em erro, mediante ardil.

Do crime de furto qualificado – artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação, devendo ser acolhidas as alegações finais do Ministério Público que sustentou a tese de absolvição por falta de provas.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do furto ao ora acusado. Com relação a essa imputação nenhuma testemunha foi ouvida em juízo.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição do réu. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

No mais, conforme preleciona Aury Lopes Jr "o Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e, sem o seu pleno exercício, não se abre a possibilidade de o Estado exercer o poder de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP mediante o exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo".

Da circunstância agravante de pena prevista na alínea "j" do inciso II do artigo 61 do Código Penal (ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública).

Com efeito, em que pese o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da pandemia de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 2ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Não se nega a situação para lá de delicada que o mundo vive, mas a agravação da pena deve ser reservada a casos concretos, nos quais o agente se vale da calamidade pública para a prática do delito, como a hipótese de desvio de verba pública

destinada à saúde ou o superfaturamento de itens essenciais ao combate do vírus mortal". (Apelação Criminal nº 1525440-21.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Rel. Francisco Orlando, 24 de fevereiro de 2021 – grifos nossos).

No mesmo sentido: V. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021, e Habeas Corpus nº 629.867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 1º de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de estelionato, nos exatos moldes do artigo 171, caput, do Código Penal.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito de estelionato descrito na denúncia.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base. Assim, considerando ainda que a culpabilidade não ultrapassa o normal desvalor da conduta, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de estelionato.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência. Com efeito, extrai-se da Folha de Antecedentes (fls. 119/124) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 141/145) que o réu ostenta condenação anterior por crimes de roubo majorado e corrupção de menor (processo nº 0001153-25.2017.8.26.0050, da 27ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 03/09/2018). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), culminando com a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de estelionato que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

Diante da quantidade de pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de (1) CONDENAR o acusado DIEGO HENRIQUE LIMA DE SOUSA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por

prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 11 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo e, (2) ABSOLVER o acusado DIEGO HENRIQUE LIMA DE SOUSA, qualificado nos autos, da imputação de prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu por esse processo em liberdade, faculta-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ), nos termos da Resolução nº 474 do CNJ.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA